

1500435-23.2022.8.26.0617
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/06/2022
... a droga ventilada para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes legais, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico e a motocicleta, instrumento, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de suas origens lícitas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
2ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu
CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500435-23.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500435-23.2022.8.26.0617 2022/000270
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISABELA DOS SANTOS SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

DIEGO RODRIGO CÂNDIDO DE PAULA e ISABELA DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material de delitos, porque, segundo narrou a inicial, em data incerta anterior a 28.03.2022 e também neste dia, nesta cidade e comarca, associaram-se entre eles e com outros indivíduos não identificados para a prática, reiteradamente ou não, de tráfico de drogas.

Ainda, segundo a denúncia, no dia 28.03.2022, por volta das 19h, na Avenida dos Cegonheiros, Jardim Valparaíba, nesta cidade e comarca, DIEGO RODRIGO CÂNDIDO DE PAULA e ISABELA DOS SANTOS SILVA, previamente associados entre eles e com terceiros não identificados, traziam consigo e transportavam, sem autorização, para fins de tráfico, porções de cocaína, algumas sob a forma de crack substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificados os acusados para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos às fls. 150/151 e fl. 160.

Recebida a denúncia em 13.05.2022 (fl. 161), os réus foram citados pessoalmente (fl. 239 e fl. 257) e requisitados para audiência, oportunidade em que foi colhida a prova oral e os acusados interrogados (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência em parte, condenando-se os réus nas penas do delito de tráfico, nos moldes da inicial, e absolvendo-os quanto à imputação relativa à associação, por falta de provas (arquivo digital).

A defesa da ré ISABELA, a seu turno, buscou a absolvição nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a fixação de regime menos gravoso; o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

A defesa do réu DIEGO, por sua vez, buscou a absolvição do acusado quanto ao crime de associação, por falta de provas. Em relação ao tráfico, a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; a detração penal do tempo em que ficou preso provisoriamente; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A ré ISABELA, interrogada perante a autoridade policial, disse que vive maritalmente com DIEGO, e que há cerca de três meses começou a fazer entregas de drogas no bairro Vila Guarani, esclarecendo que fica em casa enquanto ele vai até um local desconhecido, recebe a droga e depois o acompanha até o bairro. Não sabe dizer quem recebe as drogas de DIEGO, pois apenas o acompanha, ficando com algumas amigas enquanto ele faz a entrega diariamente, não sabendo dizer quanto o companheiro recebe pelo serviço. Não sabia que havia drogas na mochila que carregava no dia dos fatos, nunca tendo sido presa ou processada (fl. 20).

O réu DIEGO, interrogado perante a autoridade policial, afirmou que há cerca de 30 meses trafica pelo bairro Vila Guarani, recebendo as drogas pela manhã de indivíduo desconhecido, deixando um pouco de entorpecente com outra pessoa, que faz a venda durante o dia, retornando ao bairro na parte da noite para abastecer a "biqueira". ISABELA nada sabe sobre os fatos, apesar de carregar sua mochila e de o acompanhar até o destino das drogas, tendo em vista que nunca contou a ela o que havia no interior da mochila, ressaltando que recebia R\$ 600,00 por cada vez que transportava drogas até o bairro Vila Guarani. Já foi preso e processado por tráfico de drogas, bem como apreendido por ato análogo (fl. 21).

O réu DIEGO, interrogado em juízo, afirmou, em confuso depoimento, que se equivocou na delegacia de polícia ao dizer que transportava droga há três meses, visto que na realidade fora contratado para realizar o transporte por três dias, tendo feito uma

vez apenas, na data da prisão. Contraditoriamente, disse na sequência que transportara droga para o mesmo local uma outra vez com sua esposa. Ela não sabia de nada. Ela carregava a mochila que era de sua titularidade, em cujo interior, afora a droga e dinheiro, havia uma bolsa de sua propriedade. Ganhava R\$ 600,00 por transporte, e utilizaria o dinheiro (total de R\$ 1.800,00) para consertar seu veículo. Ajudava sua esposa a vender doce e sua mãe com reciclagem. A motocicleta era de sua mãe (arquivo digital).

Já a ré ISABELA afirmou que dirigiu-se até a Vila Guarani na companhia de seu esposo, com quem é casada há quinze anos, carregando a mochila dele, desconhecendo seu conteúdo. Apenas quando a polícia os abordou é que soube da presença de droga, dinheiro, e papel com anotações em seu interior. Iria até a casa de uma amiga. Foi até a Vila Guarani com Diego uma outra vez, dirigindo-se também à casa da mesma amiga, permanecendo seu marido na trilha do trem, não sabendo o que ele ali fez. Trabalhava vendendo doces e roupas íntimas femininas, possuindo renda mensal de aproximadamente R\$ 500,00. Seu marido não trabalha. Mora na casa de sua mãe, que também os ajuda a complementar a renda. Na delegacia, assinou o depoimento sem ler, e jamais falou que transportava droga há três meses (arquivo digital).

Os policiais militares LUCIANO TAVARES E LUIS PAULO SANTIAGO asseveraram que em patrulhamento pelo local avistaram a motocicleta conduzida pelo réu, em cuja garupa estava a ré. Ela, notando a presença da viatura, passou a insistentemente olhar para trás em sua direção, aparentando possuir algo na cintura. Em abordagem, apreenderam, na mochila ventilada, a droga e dinheiro em questão, admitindo ambos os réus que transportavam droga até a Vila Guarani há três meses (arquivo digital).

As testemunhas de defesa ROGÉRIA CRISTINA DE ANDRADE E SOUSA e ELISANDRA APARECIDA CRUZ apenas abonaram conduta social da ré, não presenciando os fatos (arquivo digital).

O laudo de fls. 16/19 atestou que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína.

Foi acostado aos autos laudo dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 192/205).

A confissão judicial de DIEGO nas duas etapas da persecução penal, aliada à palavra dos agentes, apreensão de droga e dinheiro na posse dos réus, e prova pericial, são elementos bastantes a demonstrar a prática pelos acusados do delito de tráfico.

De fato, os réus foram flagrados juntos na motocicleta, portando ISABELA a mochila. Sua alegada inocência não se compraz com essa conduta, afora a atitude suspeita que manteve ao notar a presença da polícia, consistente em insistentemente olhar para trás na direção da viatura. Não bastasse, ela na fase policial admitiu transportar droga há três meses, informação essa também corroborada na mesma etapa pelo corréu, que em juízo admitiu ter prestado essa informação na oportunidade, mas no entanto se confundira...

Frise-se que os agentes não conheciam os réus antes dessa abordagem e nada há nos autos a demonstrar interesse deles em falsamente incriminá-los.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Sumulando, a palavra dos policiais, que apreenderam expressiva quantidade de drogas

na posse dos réus (131,4 g de cocaína), além de papel para anotações com a contabilidade do comércio espúrio e elevada quantia em dinheiro (R\$ 1.475,00), elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que os acusados traziam consigo e transportavam a droga ventilada para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes legais, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico e a motocicleta, instrumento, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de suas origens lícitas, pelo que devem ser decretadas suas perdas em favor da União.

Saliente-se que a Constituição Federal determina a expropriação dos bens, em favor do Estado, que sejam instrumento, produto ou proveito do tráfico de drogas (art. 243, parágrafo único), devendo eventual direito de terceiro de boa-fé ser dirimido pela via própria.

Veja-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários em que reconhecida a Repercussão Geral:

"TEMA 647. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento". (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade dos acusados.

Delito do art. 35, caput, da Lei de Tóxicos.

Em relação a este crime, tenho que os acusados merecem ser absolvidos, na forma do art. 386, II, do Código de Processo Penal, como reconhece o Ministério Público.

Não ficou demonstrada, com a segurança exigida para a prolação de um édito condenatório na seara criminal, estivessem os réus associados, de modo estável, organizado e permanente para a prática de tráfico, a ensejar a tipificação do delito ventilado. Para tanto, necessário seria investigação mais cuidadosa, não realizada, não bastando a tanto a quantidade de droga apreendida.

Com efeito, cuidou-se de flagrante accidental, não precedido de qualquer ato investigativo ou cautelar penal (busca e apreensão, interceptação telefônica, e.g).

A prova de eventual societas sceleris, pois, é frágil, sendo inapta a forjar a condenação dos acusados.

Nessa esteira, a Jurisprudência Bandeirante:

"APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. Insurgência da acusação

contra a r. sentença de parcial procedência, que condenou o sentenciado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06. Pleito de reconhecimento do delito previsto no artigo 35, do mesmo diploma legal(...) mantida a absolvição dos respectivos sentenciados da imputação relativa ao delito capitulado no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Associação que exige reunião estável e permanente para a prática de série indeterminada de crimes relativos ao tráfico de drogas. Descaracterização(...) (TJSP; Apelação 0011209-59.2015.8.26.0577; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro: 09/10/2017).

Resta fixar as reprimendas.

I - Ré ISABELA.

A ré não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade da droga apreendida (131,4 g de cocaína), não se olvidando expressiva quantia em dinheiro (R\$ 1.475,00), tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica da acusada.

Não há agravantes nem atenuantes.

Inexistem causas de aumento.

Como a ré é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas de metade (§ 4º do art. 33), totalizando 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe ante as circunstâncias e consequências especialmente gravosas do delito, anotando-se, nesta etapa, o concurso de agentes e haver a ré admitido, na etapa extrajudicial, efetuar o transporte de droga há três meses.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º).

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

As circunstâncias do delito, já expostas, indicam que a substituição de pena, na hipótese, não é suficiente a reprovar e prevenir o presente crime (art. 44, III, do Código Penal).

A quantidade da reprimenda obsta a concessão de sursis.

II - O réu DIEGO.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente específico. A condenação referente ao processo nº 0774800-61.2009.89.26.0577, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 11.05.2010 e para Defesa em 17.06.2010 (fl. 45), cujo lapso depurador não decorreu, pois foi extinta pelo cumprimento em 15.09.2021, é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0000706-18.2011.8.26.0577, da 3ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 28.07.2015 e para Defesa em 13.10.2015 (fl. 45), posteriormente na consideração da reincidência específica, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento". (RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade da droga apreendida (131,4 g de cocaína), não se olvidando expressiva quantia em dinheiro (R\$ 1.475,00), tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art.543-C, do Código de Processo Civil/73:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Registro, nesse passo, que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada."

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Inexistem causas de aumento.

Anoto que devido à reincidência específica do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma que atende a todos os princípios jurídico-penais, não ofendendo a isonomia; antes, garantindo plena individualização da pena.

O regime de cumprimento de pena, ante sua reincidência, quantidade, e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A mera quantidade da reprimenda, além de recidiva e circunstâncias judiciais desfavoráveis, obstam a substituição ou concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo a denúncia:

a) IMPROCEDENTE EM PARTE para absolver DIEGO RODRIGO CÂNDIDO DE PAULA E ISABELA DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, da acusação de terem praticado o delito do art. 35, caput, da Lei de Tóxicos, o que faço na forma do art. 386, II, do Código de Processo Penal;

b) PROCEDENTE EM PARTE para condenar, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

b.1) DIEGO RODRIGO CÂNDIDO DE PAULA qualificado nos autos, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado;

b.2) ISABELA DOS SANTOS SILVA, qualificada nos autos, a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão (regime inicial semiaberto), além de de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado;

Decreto a perda, em favor da União, da motocicleta e do dinheiro apreendidos.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Sem condenação do réu DIEGO em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Custas da ré ISABELA ex lege.

Deverá o acusado DIEGO permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontra.

Tendo a ré ISABELA respondido ao processo em liberdade, e não havendo novas

circunstâncias a determinar sua prisão, não sendo suficiente a sentença condenatória recorrível, poderá apelar em liberdade.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 15 de junho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA